

Cám. Apel. Flia., Mendoza, 30/12/2024, "S., M. A. y otros c/T., I. Y. p/Régimen de Comunicación"

En la ciudad de Mendoza, a los treinta días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara de Apelaciones de Familia, los jueces Dres. Germán Enrique Ferrer, María Delicia Ruggeri y Estela Inés Politino y traen a deliberación para resolver en definitiva la causa N° 25.111/22 "S., M. A. y otros c/T., I. Y. p/Régimen de Comunicación" originaria del GEJUAF Las Heras de la Primera Circunscripción Judicial, venida a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Dra. María Victoria Periri por la demandada y por sus honorarios contra la sentencia del 13 de noviembre de 2023 por la que se dispone la revinculación de S. S. T. con sus abuelos paternos, Sres. M. A. S. y L. A. M., a llevarse a cabo por intermedio del área Puntos de Encuentro Familiar (dependiente de la SCJM, Ley provincial 8647); sin perjuicio de la iniciación o continuación de las terapias individuales que los involucrados estuvieren realizando; impone las costas en el orden causado y se regulan los honorarios de los profesionales intervinientes. Habiendo quedado en estado, se fija el orden de los votos que prevé el artículo 140 del C.P.C.C.yT., arrojando el siguiente orden de estudio: Dres. Ferrer, Politino, y Ruggeri.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

Primera: ¿Es justa la sentencia apelada?

Segunda: Costas.

Sobre la primera cuestión, el Dr. Germán Ferrer dijo:

I.— La juez que nos precedió en el juzgamiento luego de referirse a las normas convencionales y nacionales en las que se enmarca el conflicto, señala que se han realizado pericias psicológicas a S., su progenitora y a sus abuelos paternos y se escuchó al niño. Ante la negativa de S. para vincularse con sus abuelos, estima que procurar el restablecimiento del vínculo del niño con sus abuelos paternos es una tarea que en caso de darse llevará un trabajo interdisciplinario en donde no solo desde lo jurídico pueda brindarse una respuesta, sino que desde lo práctico pueda acompañarse, teniendo como fin la protección del superior interés de S.. Pero no obstante lo señalado, y teniendo en cuenta las disposiciones de la ley 8.641 vigente en la provincia en la que se establece la creación y regulación de los Puntos de Encuentro Familiar para que desarrollen sus actividades en el ámbito de la

Provincia de Mendoza, estima conveniente derivar los presentes autos a fin de comenzar un nuevo proceso de revinculación de S. con sus abuelos paternos en forma gradual y progresiva, asistida y conjunta por los profesionales competentes e idóneos del Área Puntos de Encuentro como lo ha solicitado el Ministerio Pupilar en su dictamen final.

II.— La apelante expresa agravios. Sostiene que S. ha sido claro al expresar en forma categórica, en las audiencias, que no desea ver a sus abuelos. Señala que la Asesora en la audiencia del 19/10/2019 dictaminó en el sentido de que no estaban dadas las condiciones para que se pueda proceder a un régimen de comunicación. Aduce que debe primar en la resolución el interés superior de S. (art. 3 CDN y art. 3 ley 26061). Y, relacionado con el derecho a ser oído, expresa que S. manifestó de manera convincente, libre y autónoma, su voluntad de no tener contacto de ningún tipo con sus abuelos, tanto al momento de la pericia, como en la audiencia con la a quo y la asesora; sin embargo, se desoyó por completo dicha voluntad, representando una violación del derecho a ser oído amparado por el art. 12 CDN. Se agravia de la valoración hecha de la prueba pericial psicológica invocada en el fallo. Transcribe parte de la pericia psicológica realizada por el CAI SM al abuelo paterno: “Se detectan como características de personalidad dificultad para expresar sus emociones, auto centramiento, con marcadas fallas en la capacidad de autocrítica y en la capacidad empática. A nivel cognitivo presenta marcada rigidez, tendencia a imponer sus criterios en el entorno, baja tolerancia a la frustración,

baja capacidad de espera ante situaciones contrarias a sus expectativas, y/o novedosas o estresantes; con posibilidad de tornarse irascible, irritable con déficit en el control de impulsos y emociones como así también en poder modular y/o flexibilizar conductas o comportamiento”. Y de la abuela: “Si bien posee un funcionamiento de tipo lógico formal, se detecta rigidez y dificultad para resolver asertiva de conflictos; con posibilidad de dificultades en el manejo de emociones ante situaciones contrarias a lo que considera adecuado y/o que le generen altos niveles de ansiedad”. Infiere que los abuelos no representan una estructura estable para el niño. Cuestiona la falta de fundamento para disponer las terapias bajo mandato. Pide la revocación del fallo recurrido.

III.— Los apelados, debidamente notificados del traslado de los agravios, no contestan.

IV.— El 5 de noviembre de 2024 se lleva a cabo en la alzada la audiencia fijada para dialogar con S., con la participación de la Asesora de NNyA.

V.— La Asesora de NNyA dictamina y en lo relevante para resolver el recurso expresa: “...Que en la audiencia mantenida en fecha 20 de octubre de 2023, este Ministerio expresó que no están dadas las condiciones para disponer un régimen de comunicación en este contexto, ello porque consideré que la negativa expuesta por S. obsta a cualquier intento de revinculación y forzarlo sería contraproducente

para el resultado del mismo. En este sentido, propicié la intervención de Puntos de Encuentro Familiar, organismo dependiente del Poder Judicial de Mendoza que cuenta con profesionales abogados a analizar y evaluar la conveniencia o no de iniciar un proceso vincular, cuando un vínculo se ha roto, como en el caso de autos. Así las cosas, la intervención de dicha oficina es previa a cualquier intento de vinculación, donde los profesionales especialistas en la materia evaluarán, conforme a su experticia, la conveniencia o no de fijar pautas para llevar a cabo una posible revinculación entre S. y sus abuelos paternos. [...]Es decir, la sentencia atacada no ha dispuesto un régimen de comunicación sino la intervención de Punto de Encuentro Familiar en el marco de la Ley 8467. Por ello entiendo que disponer la intervención de Puntos de Encuentro garantiza el superior interés de mi representado, pues en este espacio, acompañado por un equipo interdisciplinario de profesionales neutrales, S. podrá expresar libremente su opinión respecto a la cuestión aquí debatida asegurándose el ejercicio pleno de sus derechos en tanto partícipe necesario de la definición que surja a partir de la intervención dispuesta. Por lo expuesto, en función de la normativa citada y de conformidad con lo manifestado, este Ministerio propicia el rechazo del recurso de apelación interpuesto. Despacho, 13 de noviembre de 2024 Carola L. Pardo CoAsesora Asesoría de niños, niñas y adolescentes y personas con capacidad restringida Las Heras”.

VI.— El derecho-deber de comunicación entre parientes está contemplado por el art.555 del CCyC, estableciendo con claridad a los legitimados activos (ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales o unilaterales y parientes por afinidad en primer grado) y a los legitimados pasivos (los que tengan a su cargo el cuidado de personas menores de edad, con capacidad restringida, enfermas o imposibilitadas). La norma también prevé que la oposición al contacto debe fundarse en posibles perjuicios a la salud mental o física de los interesados, por lo que la ley presume el beneficio del contacto entre las personas beneficiarias. Las causales deben ser fundadas e interpretadas con carácter restrictivo y la petición solo puede ser rechazada cuando se acredite un daño a la salud física o correcta formación integral del beneficiario, que afecte su desarrollo en forma perniciosa. Para tal fin, tratándose de un menor de edad, deben tenerse en cuenta los principios fundamentales que hacen a la protección de los derechos de la infancia, el interés superior y el derecho a ser oído y que su opinión sea tomada en cuenta. (Conf. Mariel Molina de Juan, en Tratado de Derecho de Familia, Aída Kemelmajer de Carlucci y otras., dirs., Ed. Rubinzal Culzoni, 2014, T° II, ps.380/386). “La finalidad del derecho de comunicación transita los carriles de los deberes de asistencia familiar, del apoyo moral, espiritual o material entre diversas circunstancias de la vida, del contacto personal y la preservación de los afectos; en definitiva del afianzamiento de los vínculos familiares o afectivos entre los parientes o terceros con interés afectivo que no conviven. Se trata de un derecho-deber que encuentra su fundamento en la solidaridad familiar, en la necesidad de integrar la familia, y

resguardar los vínculos afectivos.” (Faraoni, Fabián, El Derecho de Comunicación entre los Parientes, en Tratado de Derecho de Familia, Adriana Krasnow, dir., Ed. La Ley 2015, p.734).

VII.— Ingresando al análisis de lo que ha sido materia de agravio, la apelante no ha logrado revertir los fundamentos dados por la juez a quo, sobre todo porque si bien ha reconocido el derecho a comunicación entre los abuelos paternos y su nieto por surgir de la normativa legal vigente en la materia, su implementación, la ha supeditado a la previa intervención del equipo de profesionales del programa Puntos de Encuentro Familiar, por lo que S. no se verá sometido a situaciones no queridas, respetando sus tiempos. La actitud asumida por la progenitora deja traslucir la existencia de una fuerte conflictiva y encono con el progenitor y los abuelos paternos, sin poder advertir lo perjudicial que resulta para el niño sumirlo en un conflicto de lealtades, lo que he podido apreciar en las audiencias video grabadas. Resulta claro que la apelante no puede diferenciar sus intereses y necesidades personales de aquellos intereses y necesidades que benefician el desarrollo armónico e integral, psíquico y afectivo-emocional de su hijo, en una etapa fundamental de su vida en la que van moldeando su personalidad. La armonía en los lazos familiares resulta ser un factor esencial para dicho cometido. Los abuelos cumplen, en la mayoría de los casos, un rol fundamental en esta misión, colaborando con los padres en la crianza de los hijos, apoyándolos espiritual, afectiva y materialmente (cfr. Mariel Molina de Juan, op. cit., p. 79). Como lo pone

de relieve la juez, de los elementos de prueba existentes no surge que los abuelos puedan representar para su nieto un peligro de sufrir un daño grave como se exige por la doctrina y la jurisprudencia imperantes, con fundamento en el art. 555 del CCyC, para rechazar la fijación del contacto, más allá de los lógicos rasgos de personalidad deficitarios que, en general, todos los seres humanos tenemos por nuestra propia naturaleza y conformación, que pone de relieve la apelante en relación a ambos abuelos. Es que, como se ha dicho: “La determinación del derecho de comunicación debe atender a las múltiples realidades que rodean a los involucrados, procurando siempre el fortalecimiento del vínculo familiar y el contacto estable, por lo que la modalidad de su ejercicio estará sujeta a una diversidad de variables de acuerdo a la forma en que se encuentre reglamentado.” (Faraoni, op. cit., p.758). En lo que respecta al derecho de S. a ser oído y a que su opinión sea tomada en cuenta en función de su grado de madurez y desarrollo (art.12 CDN y arts. 3, 24 y 27 de la ley 26.061), de la audiencia mantenida en esta Cámara me quedó la impresión de que S. responde a un conflicto de lealtades con su madre estando su discurso impregnado de influencia adulta, sin fundamentos reales y ciertos que hagan entendible su negativa rotunda a comunicarse con sus abuelos. Se refirió a un episodio en que sus abuelos se presentaron en su casa pretendiendo que se comunicara con su papá por celular y en el que intervino su mamá generándose una situación conflictiva. Luego preguntado si había tenido con anterioridad algún otro problema con sus abuelos, cuenta otro suceso en que los abuelos pretendieron verlo y llamaron a la policía y al no poder hacer nada, el

abuelo lo insultó. Resulta llamativo que, cuando es escuchado en primera instancia —octubre de 2019— siendo notoriamente menos maduro, con aspecto de niño, cuando se le pregunta el motivo por el que no ve a los abuelos dice que en realidad es porque se peleó con el papá —le dio a probar alcohol y cigarrillos— y dado que los abuelos viven al lado dejó de verlos. Seguidamente relata que los abuelos iban sin avisarle a su mamá a su casa a verlo, pretendiendo que hablara con su papá, situación que lo ponía mal. Ahora bien, en ningún momento, ni en la audiencia de primera instancia, ni en la de Cámara, S. se muestra angustiado o afectado emocionalmente cuando relata estos sucesos, mostrando un discurso racional carente de sentimientos. En este sentido hemos dicho: “Escuchar a los niños, niñas o adolescentes —de conformidad con lo dispuesto por los arts. 5, 12 y cc. de la C.D.N y en especial por los arts. 3 incs. a), b), d); 24 y 27 de la ley 26.061 — y por los arts. 26, 639 y 706 del CC y C— no implica que deba atenderse necesariamente a sus preferencias expresadas, si de los elementos colectados en la causa surge que satisfacerlas no es conducente al logro de su superior interés, en cuyo caso se torna necesario equilibrar esa posible frustración, orientándolos a la comprensión de la decisión y sus motivos, siendo indispensable en tales supuestos que el juez exprese los motivos de su apartamiento de la opinión recogida.” (Expte. 231/13 M., T. L. C/ V. A. P. P/Tenencia, 14/10/2015). Claramente el opositorismo o resistencia principal para que S. vea a sus abuelos viene por el lado de la progenitora, si bien en forma encubierta, utilizando al hijo como objeto de disputa, posiblemente a partir de la ruptura de la relación afectiva con el papá

de S., resultando de la frustración del proyecto de pareja, en muchos casos, el encono generalizado con toda la familia del otro cónyuge o conviviente, privando a los hijos del trato con sus abuelos, tíos y primos. Lamentablemente, esta realidad se repite frecuentemente en la mayoría de los casos análogos que nos toca resolver. Desde esta perspectiva y como acertadamente lo destaca la Asesora en su dictamen, lo decidido no vulnera los derechos de S., ni lo expone a situaciones no queridas, sino que busca que los adultos responsables, incluidos también en esto los abuelos paternos a fin de que puedan visualizar aquello que ha molestado a su nieto, con ayuda profesional desde un ámbito institucional, puedan facilitar las condiciones, a través de conductas positivas, para que S. pueda disfrutar del vínculo y el afecto de sus abuelos, lo que seguramente redundará en su beneficio personal y en su interés superior (art. 3 CDN y art. 3 ley 26.061). En otros precedentes análogos de esta Cámara hemos confirmado las resoluciones que daban intervención al programa de Puntos de Encuentro Familiar para intervenir en la conflictiva familiar, a fin de propiciar la reanudación paulatina de los contactos familiares interrumpidos (cfr. Expte. 1188/18 V. C. S. contra S. B. M. por Régimen de Comunicación, 14/10/2024; Expte. 12289/22 M., D. H. c/ L., C. A. p/ Med. Cautelar, 10/04/2023; Expte. 645/20 S., M. C. c/ R., J. A. p/ Medidas Precautorias, 19/10/2022). Por lo que propicio el rechazo del recurso en trato. En relación a la Dra. María Victoria Perri, en el escrito por el que interpone el recurso de apelación, expresa que lo hace por la demandada y por sus honorarios; al expresar agravios nada dice sobre este tópico, por lo que no corresponde

pronunciarse al respecto dado que, conforme al decreto del 9/9/2024, se dispuso que expresara agravios la parte apelante sin proveer diferenciadamente la apelación de honorarios (art.40 del CPCCyT), lo que fue consentido. Así voto.

Las Dras. Politino y Ruggeri adhieren al voto que antecede por sus fundamentos.

Sobre la segunda cuestión, el Dr. Germán Ferrer dijo: Teniendo presente la forma en que se resuelve el recurso de apelación, las costas de alzada deben imponerse a la apelante vencida (art.36 I del CPCCyT). Así voto.

Las Dras. Politino y Ruggeri adhieren al voto que antecede por sus fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, pasándose a dictar sentencia, la que a continuación se inserta.

SENTENCIA:

Mendoza, 30 de diciembre de 2.024.

Y VISTOS: Por los motivos dados, el Tribunal. RESUELVE:

I.— No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la resolución del 13 de noviembre de 2023.

II.— Imponer las costas de alzada a la apelante.

III.— Regular los honorarios profesionales de la Dra. M. V. P., en la suma de pesos ochenta y tres mil novecientos setenta y nueve (\$83.979) (arts. 3, 15 y 31 de la ley 9.131 y art. 33 III del CPCCyT). Notifíquese y bajen.

FDO.: FERRER — POLITINO — RUGGERI.